

1500939-81.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500939-81.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500939-81.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2085759/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 17034605 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

753/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2085759 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 753/21/923 -

DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAYMON CLEMENTE DA SILVA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

SAYMON CLEMENTE DA SILVA e JOÃO VITOR ARAGÃO DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Conforme consta do incluso inquérito policial, no dia 28 de março de 2021, por volta das 10h28min, na Rua Joaquim Carlos Wissel, próximo ao número 138, bairro Parque Hipólito II, nesta cidade e comarca, o denunciado Saymon trazia consigo e o denunciado João transportou, ambos para entrega a consumo de terceiros, aproximadamente 70,57g (setenta gramas e cinquenta e sete centigramas) da droga cocaína, acondicionados em 147 microtubos plásticos, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de exibição e apreensão e laudo de exame químico toxicológico).

Segundo restou apurado, João Vitor, utilizando de uma motocicleta, transportou a droga acima descrita até a Rua Joaquim Carlos Wissel, e a entregou a Saymon que, por sua vez, efetuará a entrega da droga a terceira pessoa, tudo com a finalidade

de comercialização ilegal, diante da quantidade e forma como a droga estava acondicionada (147 microtubos contendo cocaína).

A entrega da droga por João Vitor a Saymon foi presenciada por guardas municipais que realizavam patrulhamento naquela via pública, que ao avistarem a viatura, ambos se evadiram, entretanto, o denunciado Saymon foi alcançado e dispensou ao solo a sacola contendo as drogas que havia recebido de João, sendo preso em flagrante delito.

Perante a autoridade policial, Saymon confessou a prática do crime, dizendo que, conforme havia combinado com João, dele recebeu a droga que deveria repassar a um indivíduo de prenome Wilson. O denunciado João Vitor foi localizado posteriormente e negou os fatos.

Oferecida à denúncia, determinou-se a notificação dos réus para que apresentassem defesas preliminares (fls. 105 e 107), que vieram aos autos (fls. 119/123).

A denúncia foi recebida em 20 de junho de 2022 (fls. 124/126).

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas, bem como interrogados os réus ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se.

Alegações finais do Ministério Público (fls. 163/168) e da Defensoria Pública (mídia).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03), boletim de ocorrência (fls. 16/18), auto de exibição e apreensão (fls. 19), laudo pericial com resultado positivo para cocaína (fls. 51/53 e 157/159), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Em solo policial, o acusado Saymon confessou os fatos. Disse que na manhã foi até a Rua Joaquim Carlos Wissel, local onde havia combinado de encontrar com o denunciado João para pegar uma porção de cocaína e levar até Wilson, que até então não sabe de quem se trata. Afirma que, após João lhe entregar a porção de cocaína, visualizou a viatura da Guarda Civil Municipal se aproximar, momento em que seu comparsa João conseguiu se evadir do local, mas ele foi abordado pelos guardas. No momento em que os guardas se aproximaram, dispensou as drogas que estavam consigo. Diz que durante a revista pessoal foi encontrado um aparelho celular Samsung, pertencente a uma pessoa que fica na praça um pouco abaixo de onde foi abordado. Afirma que o proprietário desse celular é quem o contratou para levar as drogas. Confirma que os guardas viram ele dispensar as drogas e o questionaram, o qual confirmou que era responsável para fazer o transporte dos entorpecentes. Os guardas deram voz de prisão em flagrante e o conduziram até a delegacia. Alegou nunca ter sido preso e nem processado (fls. 06).

Em Juízo, o acusado Saymon disse que tem 19 anos. Está desempregado. No dia em questão, a viatura apareceu de surpresa. Não escutou o nome do rapaz da

motocicleta. Precisava de dinheiro. Fez essa besteira e recebeu as drogas. Não pode confirmar se era o corréu João o condutor da motocicleta. O ocupante da motocicleta estava de capacete. Chegou a falar o nome de João Vitor em solo policial, mas falou por ficar assustado. Ficou no ponto da biqueira, pegou com o motociclista a droga e iria levar uma rua depois, só iria fazer a entrega, sem fazer qualquer venda. Havia um tal de motoca no local. Pegou o telefone celular na rua, é usuário de drogas. Acredita que a motocicleta era de cor verde e era barulhenta (mídia).

Em solo policial, o acusado João Vitor negou os fatos. Alegou que nunca esteve envolvido com o tráfico de drogas e desconhece Saymon (fls. 59/60).

Em Juízo, o acusado João Vitor disse que tem 21 anos. É autônomo. Está preso por furto. Não tem envolvimento com os fatos. Não conhece o corréu Saymon. No final do ano de 2020, foi abordado pelos guardas civis. Fumava maconha e foi esculachado. Os guardas ficaram no seu encalço. É vítima de perseguição. Foi abordado por três a quatro vezes antes dessa ocorrência. Teve apenas uma motocicleta de cor vermelha. Estava trabalhando no lava-rápido na época dos fatos (mídia).

A confissão extrajudicial de Saymon encontra amparo na prova oral colhida, de modo a incriminar o corréu João Vitor.

Vejamos o teor da prova oral, contrária aos interesses de ambos os réus.

O guarda civil municipal José Ronaldo da Nobrega disse que estavam passando em frente a uma escola municipal, quando viram um motociclista entregando algo a um rapaz a pé. A motocicleta e o condutor já eram conhecidos dos meios policiais. Viu a entrega de uma sacola entre essas pessoas. Ao avistarem a aproximação da viatura, tais pessoas saíram do local, cujo motociclista tomou rumo ignorado, não sendo mais encontrado. Um suspeito foi detido logo em seguida, após ter dispensado uma sacola, jogando-a do lado do muro da escola. O acusado Saymon foi a pessoa abordada de imediato e no interior da sacola dispensada encontraram 147 (cento e quarenta e sete) flaconetes contendo cocaína. Indagado a respeito das drogas, Saymon afirmou que iria repassá-las à pessoas da Rua Higino de Barros Camargo, local este conhecido como "Wilson". Já conheciam o motociclista João Vitor, assim como a motocicleta por ele utilizada. Viu perfeitamente a entrega do pacote de João Vitor para Saymon. O motociclista estava de capacete. Sabiam que era o acusado João Vitor na posse da motocicleta pelas características físicas. O local da abordagem é um ponto conhecido de entrega de drogas. A motocicleta era verde e barulhenta. Na delegacia o acusado Saymon confirmou o envolvimento de João Vitor na prática delituosa. O denunciado Saymon disse que o motociclista entregou o pacote a ele. Não conhecia o acusado Saymon até então (mídia).

O guarda civil municipal Danilo Amaral Luna Soliz disse que a ocorrência foi simples. Faziam patrulhamento de rotina perto de uma escola. Ao chegarem à esquina, viram uma motocicleta verde, o condutor entregava uma sacola ao réu Saymon. A motocicleta acelerou ao ver a viatura. Viu Saymon jogando a sacola no jardim de uma escola. Já conhecia aquela motocicleta e o condutor João Vitor de outra abordagem. Só o acusado Saymon foi abordado. Indagado, ele disse que pegou aquele pacote com o condutor da motocicleta e iria levar a um ponto de tráfico. Viram Saymon jogando o pacote em frente de uma escola. Não houve resistência. Saymon foi réu confesso. Já conhecia o corréu João Vitor de outras abordagens, a motocicleta era costumeiramente utilizada por ele. Descreveu a cor e as características da motocicleta. A sacola dispensada por Saymon foi entregue por João Vitor. A informação era que João Vitor abastecia o local com entorpecentes. Na delegacia o acusado Saymon confirmou o envolvimento de João Vitor na prática delituosa (mídia).

Ressalto que o depoimento de guardas civis neste caso é perfeitamente válido. É inadmissível alegar que seriam suspeitos. Não restou comprovada qualquer agressão, armação ou perseguição dos agentes públicos, que não tinham qualquer motivo

aparente ou concreto para incriminar injustamente os acusados. Sobre a admissibilidade de tais testemunhos, cito o seguinte entendimento jurisprudencial:

"(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

Pelo que se verifica da prova oral colhida, guardas civis municipais realizavam patrulhamento de rotina perto de uma escola quando avistaram um motociclista fazendo a entrega de uma sacola para um terceiro, em local conhecido pela traficância. Ao perceberem a presença da viatura, eles tentaram se distanciar, tendo somente o corréu João Vitor, condutor da motocicleta, conseguido fugir.

Após abordagem, foi encontrado com o acusado Saymon cerca de 147 (cento e quarenta e sete) flaconetes contendo cocaína, o qual havia dispensado enquanto fugia dos agentes e, ao ser indagado, afirmou que foi contratado para fazer o transporte dos entorpecentes até à Rua Higino de Barros Camargo, local conhecido como "Wilson".

Não bastasse a confissão extrajudicial, Saymon apontou na delegacia que o rapaz que estava na motocicleta era o acusado João Vitor, pessoa conhecida nos meios policiais, havendo reconhecimento pelos agentes públicos da motocicleta costumeiramente utilizada pelo imputado.

Dessa forma, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à autoria do crime envolvendo ambos os acusados, haja vista a quantidade, a natureza e a forma como estavam embaladas as drogas (cocaína), as circunstâncias da prisão, o depoimento incriminador dos guardas civis municipais e a confissão extrajudicial do acusado Saymon, tudo a aponta-los como pessoas envolvidas no tráfico de drogas.

Sobre o tema em comento, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo é remansosa:

"APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 – Absolvição ou, ainda, desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas – Descabimento – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavra dos policiais militares – Credibilidade – Precedentes – Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão – Ausência de visualização de atos de mercancia – Irrelevância – Tipo misto ou de conteúdo variado – Condenação mantida (...)".

(TJSP; Apelação 0004568-50.2015.8.26.0126; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro: 11/10/2017).

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) Materialidade e autoria delitiva comprovadas, sobretudo diante dos relatos seguros dos policiais militares que participaram da diligência. Escusa ofertada pelo réu isolada no quadro probatório. Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Condenação mantida (...)" (TJSP; Apelação 0000137-25.2017.8.26.0571; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 01/03/2018).

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADA, EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO, INCONSISTENTE A NEGATIVA DE AUTORIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOCAL DA ABORDAGEM, CONHECIDO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES, MODO COMO OS ESTUPEFACIENTES ESTAVAM EMBALADOS, QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA COMPATÍVEIS COM O TRÁFICO(...)" (TJSP; Apelação 0002975-45.2014.8.26.0344; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 9ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Marília - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/09/2017; Data de Registro: 26/09/2017).

Segundo entendimento do saudoso Luiz Flávio Gomes:

"Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (GOMES, Luiz Flávio e CUNHA, Rogério Sanches (Coordenadores). Legislação Criminal Especial. Volume 6. São Paulo: Editora RT, 2009).

Não convence a negativa do réu João Vitor, pois não aponta qualquer motivo para que os agentes públicos o acusassem falsamente da participação no delito de tráfico de drogas, tampouco, para a delação do acusado Saymon perante a autoridade policial no dia da prisão.

Ademais, o fato de ter fugido no momento que avistou os guardas civis reforça seu envolvimento na prática criminosa (transporte). Não bastasse, foi reconhecido pelos agentes públicos como aquele que estava na condução da motocicleta e entregou entorpecentes ao comparsa Saymon, o que foi confirmado pelos guardas em seus depoimentos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Não se observou qualquer nulidade no testemunho dos agentes públicos, já que as testemunhas conheciam o réu João Vitor dos meios policiais, inclusive a motocicleta costumeiramente utilizada pelo agente.

A ação dos guardas municipais foi válida. É cediço que o artigo 144, § 8º, da Constituição Federal estabelece que a Guarda Civil Municipal será destinada apenas à proteção de bens, instalações e serviços dos municípios, não tendo ela, portanto, a função de garantir a segurança, bem como investigar a prática de crimes. No entanto, referida limitação não significa que a Guarda Municipal não possa prender em flagrante quem estiver cometendo um delito.

"(...) 2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das

normas Constitucionais e legais. No duro, inexistiu impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP – Rel. Min. Moura Ribeiro – j. 27.05.14; RHC 45.173/SP – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 26.05.14 e HC 109.105/SP – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima – j. 23.02.10). (...)" (TJSP; Apelação 0003302-14.2014.8.26.0627; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Teodoro Sampaio - Vara Única; Data do Julgamento: 31/10/2017; Data de Registro: 06/11/2017).

A situação trazida pela Defensoria Pública em audiência quanto à atuação da Guarda Civil Municipal não se assemelha àquela colocada em discussão por ocasião da decisão de uma das Turmas do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.977.119 (cf. STJ, REsp n. 1.977.119/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022).

Decidiu-se naquele julgamento a respeito da limitação da atuação da Guarda Municipal em diligências investigativas, inerentes à atuação da polícia judiciária. No caso em tela, no entanto, na garantia da ordem pública, não se poderia exigir que os guardas civis municipais simplesmente acionassem a Polícia Civil ou Militar para que, apenas então, fosse efetuada a abordagem dos acusados, que trocaram pacote com drogas em via pública, perto de escola, em local conhecido pela traficância, de réu (João Vitor) conhecido nos meios policiais, e apenas depois se verificasse que os réus possuíam drogas para serem transportadas.

No caso, não há evidência de atuação ilegal da ação da Guarda Civil Municipal, com a observação de que os agentes públicos somente atuaram para a manutenção da ordem pública violada pela prática do crime de tráfico de drogas.

A respeito da atuação da Guarda Civil Municipal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.281.774/SP, reafirmou a tese de que não há qualquer proibição à atuação dos guardas civis municipais, em conformidade com o voto do Ministro Alexandre de Moraes:

"Quero recordar a todos, inclusive, que, há dois anos, a lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública incluiu a guarda civil metropolitana ou as guardas civis, dentro, obviamente, do âmbito de suas competências. Jamais, no nosso ordenamento jurídico, houve a impossibilidade de qualquer do povo, inclusive a guarda civil, realizar flagrante delito. Devo aqui também, em reforço à minha argumentação, colocar que, diferentemente dos policiais integrantes da Polícia

Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida. (...).Entendo que essa interpretação do art. 144 é de cunho constitucional e tem relevância gigantesca, porque são inúmeras guardas civis em todos os municípios. Consequentemente, pelo cabimento do recurso os municípios." (STF, RE 1281774 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 18-08-2021 PUBLIC 19-08-2021).

Na mesma direção:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO". (STF, HC 212635 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 11/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 12-04-2022 PUBLIC 18-04-2022).

Aliás, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a Repercussão Geral do tema, no RE nº 608.588/SP, Rel. Min. Luiz Fux, em que se discute o alcance do art. 144, § 8º, da CF, envolvendo a atuação de guardas municipais (cf. STF, RE 608588 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 06-06-2013 PUBLIC 07-06-2013).

Não se exige a existência do efetivo comércio para a configuração do crime do artigo 33, caput, da Lei de Drogas. Basta a guarda, o transporte, o trazer consigo, ou a manutenção em depósito, com a finalidade de distribuição ou de entrega a terceiros para que o crime se consuma.

A lei penal pune a mera finalidade (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de Drogas).

Por se tratar de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que é condenável a simples possibilidade de distribuição, gratuita ou onerosa, do entorpecente.

Em comentários ao artigo 33 da Lei de Drogas, o saudoso Luiz Flávio Gomes preleciona:

"(...) Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (p.ex., expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa (...)" (GOMES, Luiz Flávio et al. Nova Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo: Lei 11.343/06 de 23.08.2006. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006).

Desse modo, demonstrada a procedência da imputação contra os acusados, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria das penas a serem aplicadas.

Concernente ao crime de tráfico de drogas, as circunstâncias judiciais dos artigos 59, do Código Penal, e 42, da Lei nº 11.343/2006, são inteiramente favoráveis aos

réus, devendo a pena-base partir do mínimo legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A natureza e quantidade de drogas apreendidas no caso em tela não justificam a exasperação da pena-base pois não se trata de quantidade elevada.

Não há agravantes. Por outro lado, deixo de aplicar qualquer atenuante (confissão judicial e menoridade), pois a pena-base já foi estabelecida no patamar mínimo, observando-se o teor da Súmula 231 do Colendo STJ.

Ausentes quaisquer causas de aumento.

Na terceira fase, sendo os réus primários, de bons antecedentes, não havendo prova de que integrem organização criminosa, aplico a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4^a, da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a reprimenda em 1/2 (metade), tornando-se definitiva a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, não sendo caso de redução no patamar máximo de 2/3 em razão da natureza e quantidade de drogas apreendidas (70,57g de cocaína, acondicionados em 147 microtubos).

Para que fique bem claro, na derradeira etapa do sistema trifásico, deve ser levada em consideração a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, causa esta que, uma vez verificados seus requisitos, deve ser aplicada.

A esse respeito, deve ser acolhido o seguinte preceito doutrinário:

“Dispõe o parágrafo, em sua parte final, sobre condições negativas de que o agente não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Toda prova negativa é difícil, de modo que militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, no caso, é do Ministério Público no sentido de demonstrar a reincidência, os maus antecedentes e a participação em atividades criminosas ou organização criminosa. Não importa que a prova seja difícil para o Ministério Público. Mais difícil seria para o réu que, por sua vez, tem o direito de não ser condenado a não ser que haja prova, ou receber, sem prova, uma pena maior quando a lei permite uma pena mais branda” (GRECO FILHO, Vicente e RASSI, João Daniel. Lei de Drogas Anotada. São Paulo: Saraiva, 2008).

O valor do dia multa será no mínimo legal.

Considerando o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no acórdão proferido no HC 118.553/MS, no sentido de que o delito de tráfico de drogas privilegiado não possui natureza hedionda, revejo meu entendimento para admitir à fixação de regime inicial carcerário mais brando aos condenados pela prática daquela infração penal.

De fato, o tráfico de entorpecentes privilegiado não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos.

A obrigatoriedade do regime inicial fechado aos sentenciados por crimes hediondos e aos a eles equiparados não mais subsiste, diante da declaração de inconstitucionalidade, incidenter tantum, do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/1990, pelo STF, no julgamento do HC 111.840/ES.

Dessa forma, fixo o regime inicial aberto para o caso em questão (apreensão de 70,57g da droga cocaína, acondicionados em 147 microtubos).

Para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos

autos, conforme Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do Colendo STF, que assim dispõem:

Súmula 440/STJ: Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.

Súmula 718/STF: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.

Súmula 719/STF: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

No mais, diante do reconhecimento do tráfico privilegiado, aplica-se a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) na fixação do regime prisional, assim como as decisões dos Tribunais Superiores (STF e STJ).

Ante a quantidade da pena imposta, a primariedade e tendo em vista a decisão do STF no sentido de que o tráfico privilegiado não pode ser considerado como crime hediondo, além da natureza e quantidade de entorpecente localizada, estando presentes os requisitos que autorizam a medida, substituto a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, a ser definida em sede de execução criminal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR os acusados SAYMON CLEMENTE DA SILVA e JOÃO VITOR ARAGÃO DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no seu menor valor, como incursos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c a redução prevista no §4º do art. 33 ambos da mesma lei.

Ante a quantidade da pena imposta, a primariedade e tendo em vista a decisão do STF no sentido de que o tráfico privilegiado não pode ser considerado como crime hediondo, além da natureza e quantidade de entorpecente localizada, estando presentes os requisitos que autorizam a medida, substituto a pena privativa de liberdade por duas restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, a ser definida em sede de execução criminal.

Como responderam soltos ao processo, poderão recorrer desta em liberdade.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual ora concedida.

Defiro a incineração da substância entorpecente apreendida, com as cautelas de praxe, pela qual representou a autoridade policial.

Após o trânsito em julgado, o nome dos réus deverá ser lançado no rol dos culpados. P.R.I.

Limeira, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA